

EL PAPEL DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA REFORMA LABORAL

María del Carmen López Aniorte
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Murcia

La negociación colectiva es un instrumento esencial en todos los sistemas democráticos. En España, desde su reconocimiento como derecho constitucional (art. 37.1. CE) y su regulación en el Título III ET, ha sido una pieza clave para equilibrar las posiciones de las partes sociales, generar dinámicas económico-empresariales eficientes y productivas, disminuir la conflictividad laboral y contribuir, con todo ello, al avance del Estado social y democrático de derecho. La cercanía de los interlocutores sociales a la realidad de cada ámbito de negociación ha permitido la adaptación de las previsiones estatutarias a las peculiaridades y necesidades del mismo. La negociación colectiva ha favorecido, asimismo, la homogeneización de salarios y de costes laborales en empresas del mismo sector, evitando situaciones de *dumping* social, al tiempo que ha ofrecido herramientas para establecer marcos normativos seguros tras el agotamiento de la vigencia de las normas convencionales.

Pero, pese al relevante papel representado por la negociación colectiva tras su reconocimiento constitucional, su regulación no ha quedado a salvo de los efectos de las sucesivas crisis económicas habidas desde la restauración democrática. Tomando dichas crisis como pretexto, su régimen jurídico se ha visto paulatina y profundamente afectado -especialmente, a partir de la reforma laboral de 2012-, entre otras medidas, mediante una abrupta ruptura del equilibrio entre las partes sociales que derivó en una devaluación salarial sin precedentes. Según el Informe EAPN España de 2018, ese año se hallaban en situación de pobreza el 14 % de las personas ocupadas, especialmente mujeres y jóvenes.

Ello evidencia que el ordenamiento laboral, pese a ser pieza clave del estado de bienestar, puede llegar a ser profundamente regresivo. Hace muchas décadas que quedó superada la creencia de que este sector del derecho constituiría un factor permanente de cambio social, que propiciaría una mejora incesante de las condiciones de vida y de trabajo de la humanidad, gracias a un incremento de la productividad derivado del desarrollo tecnológico, que permitiría, a las personas trabajadoras, disponer de mejores salarios y de más tiempo para dedicar a su vida personal y familiar.

Las crisis económicas sufridas desde hace décadas, propias del sistema capitalista, siempre han tenido efectos negativos sobre el empleo. Sin embargo, fue al ordenamiento laboral al que se culpabilizó del alto nivel de paro generado bajo el argumento de su “rigidez” y “excesivo proteccionismo”, razón por la cual, desde distintas instancias, se le exigió llevar a efecto un doble cambio regresivo. De un lado, diseñar medidas encaminadas a incidir sobre el empleo mediante el reparto del tiempo de trabajo y la

contención/reducción de las rentas salariales. Y, de otro, poner en práctica fórmulas enmarcadas dentro de lo que se vino a llamar “flexibilidad” y, más tarde, “flexiguridad”, a través de las cuales se sacrificó el progreso social en favor del económico.

Las distintas transformaciones acaecidas en el ámbito jurídico-laboral, en la línea señalada, y que se tradujeron en un paulatino debilitamiento del Estado social, tuvieron su punto culminante en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta norma supuso la respuesta del legislador a reivindicaciones procedentes de distintos ámbitos, que solicitaban la adaptación de la normativa laboral a las nuevas realidades económico-productiva y del mercado de trabajo. Y, como resultado, en lo que afecta a la negociación colectiva, se vieron alteradas la correlación de fuerzas existente entre las empresas y las personas trabajadoras, las normas que regían la ultraactividad, así como la estructura de la negociación colectiva y las reglas sobre concurrencia entre convenios. Y, a resultas de lo anterior, se potenció la proliferación de las empresas multiservicios, muchas de ellas feminizadas.

A continuación, se procede a analizar, brevemente, los aspectos arriba señalados procedentes de la reforma laboral de 2012 -centrando especial atención a la prioridad aplicativa del convenio empresarial, una de sus “medidas estrella”-, para poder entender, con posterioridad, el positivo alcance de los relevantes cambios introducidos en tales materias por parte del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo:

1) Prioridad aplicativa del convenio de empresa y subcontratación. Especialmente relevante, a los efectos de la precarización de las condiciones de trabajo generada por la reforma laboral de 2012, fue el reconocimiento de prioridad aplicativa al convenio colectivo de empresa (art. 84.2 ET) en determinadas materias (entre ellas, algunas tan relevantes como la cuantía del salario base y de los complementos salariales), medida que, unida a la deficiente regulación de las contrata y subcontratas *ex art. 42 ET*, impulsó el fenómeno económico preexistente de la descentralización productiva. El juego conjunto de arts. 42 y 84 ET permitió que aquellas empresas que contaban con sujetos legitimados para negociar convenios propios *ex arts. 87 y 88 ET*, pero que carecían de una sólida implantación sindical, pudieran devaluar, mediante la negociación de convenios empresariales, las condiciones laborales previstas en el convenio de sector, sin necesidad de alegar las causas ETOP (a diferencia de lo que sucede en el caso del descuelgue de las condiciones laborales). Esta es una de las razones de la proliferación de las empresas multiservicios en los últimos años, las cuales han estado funcionando como ETT sin serlo, eludiendo así la aplicación de la Directiva 2008/104/CE de 19 de noviembre de 2008.

Son muchos los problemas jurídicos que las empresas multiservicios han venido planteando en materia de negociación colectiva, como la ausencia -en ocasiones- de representación por la parte social, la difícil determinación del convenio colectivo aplicable, y la negociación de convenios colectivos de empresa a la baja en materia salarial, que han generado *dumping* social y precarizado las condiciones laborales de las personas trabajadoras incluidas en su ámbito de aplicación, en muchas ocasiones en sectores feminizados (es paradigmático el caso de las camareras de piso).

2) Prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa y cambios en la estructura negocial. Bajo el argumento de facilitar la flexibilidad interna, al atribuir la reforma laboral de 2012 prioridad aplicativa absoluta al convenio de empresa en materias tan relevantes como la salarial, introdujo un nuevo criterio dirigido a modificar la estructura

de la negociación colectiva, que menoscabó el papel sustancial que tradicionalmente han asumido los convenios sectoriales en su diseño y en la homogeneización de las condiciones salariales del sector, y que impedía la existencia de ventajas competitivas entre empresas del mismo ámbito productivo. La reforma laboral de 2012 rompió el equilibrio tradicionalmente existente entre la ley y el convenio en la fijación de la estructura negocial, en favor de la ley, que optó, al margen de lo acordado por los interlocutores sociales en pactos de alto nivel, por una estructura descentralizada y atomizada, capaz de provocar, en determinadas empresas, una intensa devaluación salarial.

Supuestamente, esta regulación perseguía mejorar la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias económicas adversas, y reducir, en hipótesis, los despidos cuando se plantearan tales coyunturas. Desde este planteamiento, ante caídas bruscas de la actividad empresarial, los convenios empresariales podrían introducir modificaciones en materia salarial (o en otras condiciones laborales) permitiendo que los ajustes se produjeran prioritariamente mediante rebajas salariales y, en menor medida, sobre el empleo. Sin embargo, las altas cifras de paro que se alcanzaron en los años posteriores a la reforma permiten dudar del éxito de la medida, a tal efecto.

3) Prioridad aplicativa del convenio de empresa y ruptura del equilibrio entre las partes sociales. La prioridad del convenio empresarial, en su regulación procedente de la reforma laboral de 2012, devaluaba la acción sindical, reforzaba el poder empresarial, y rompía el equilibrio entre las partes sociales, al atribuir preferencia aplicativa absoluta, entre otras materias, en la retributiva, a las unidades de negociación donde la fuerza sindical no existía o se encontraba debilitada, facilitando la devaluación salarial. Los efectos, en este aspecto, de la medida fueron de enorme magnitud, habida cuenta de las características del tejido empresarial español, nutrido, fundamentalmente, de empresas de mediano y pequeño tamaño y reducidas plantillas, donde, el poder sindical se encuentra debilitado.

La inexistencia de implantación sindical o, en su caso, la mayor ductilidad del sindicalismo de empresa frente al de sector, junto a la circunstancia de que, mediante la vía de la negociación de un convenio de empresa concurrente con prioridad aplicativa, no era preciso fundamentar la reducción de las condiciones laborales del convenio de sector aplicable en la concurrencia de causas ETOP, a diferencia del descuelgue, propiciaron una devaluación salarial generalizada, que se extendió a empresas sin dificultades.

4) Prioridad aplicativa del convenio de empresa y *dumping* social. La prioridad aplicativa absoluta del convenio de empresa en materia salarial no solo perjudicaba a las personas trabajadoras, sino también a las empresas a las que se aplicaba un convenio de sector que preveía mejores condiciones laborales que las establecidas en empresas del ramo con convenio propio. Las primeras, situándose en “desventaja competitiva” respecto de las que poseían un convenio específico, aspirarían a tener su propia norma convencional, para minorar costes de personal. En esta carrera hacia la devaluación de las condiciones salariales y retributivas, se encontrarían en mayor “desventaja” las microempresas con menos de seis personas trabajadoras pues, al carecer de representación unitaria (art. 62.1 ET), no tendrían sujetos legitimados por la parte social *ex art.* 87.1 ET para la negociación de convenios colectivos concurrentes, quedando necesariamente incluidas en el ámbito aplicativo del convenio sectorial.

5) Limitación temporal de la ultraactividad a un año. La restricción temporal de la prórroga provisional de los convenios colectivos tras su denuncia (o de la llegada de su término final, de haberse excluido aquella) constituye uno de los aspectos de la reforma

laboral de 2012 que más dudas jurídicas y críticas ha suscitado, por generar una enorme inseguridad jurídica. Tal previsión, que hacía recaer las consecuencias negativas de la falta de acuerdo en la parte social, podía provocar vacíos de regulación ante supuestos de inexistencia de convenio colectivo de ámbito superior aplicable tras el agotamiento de la ultraactividad de una determinada norma convencional; suscitar dudas respecto de cual era dicho convenio de ámbito superior aplicable; y plantear interrogantes cuando el convenio de ámbito superior no regulaba todos los aspectos que contemplaba el convenio agotado, muchos de ellos definitorios de los elementos esenciales de los contratos incluidos en su ámbito de aplicación. A estos interrogantes intentó dar respuesta la jurisprudencia, con mejor o peor fortuna.

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, ha conseguido revertir los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 en materia de negociación colectiva (entre otros aspectos). En general, como señala su Preámbulo, la norma establece modificaciones “en la arquitectura de la negociación colectiva, en aspectos tales como la ultraactividad de convenios y la relación entre convenios sectoriales y de empresa, asegurando las cautelas y garantías para que la descentralización de los convenios colectivos no provoque un efecto devaluador de costes retributivos o desventajas injustificadas entre las empresas, y aporte flexibilidad en la medida adecuada”. Además, “recupera el papel central y se fortalece el ámbito legítimo de actuación de los sujetos negociadores de los convenios colectivos”. Particularmente, los objetivos perseguidos en la materia por la reforma laboral de 2021 son:

1) Recuperar, con la modificación del art. 84.2 ET, la prioridad aplicativa del convenio sectorial en materia salarial. Con ello, la negociación colectiva empresarial ya no puede ser utilizada como instrumento de flexibilidad interna sustitutiva del descuelgue (que sí requiere ser justificado mediante las causas ETOP), al tiempo que se homogeneizan las condiciones salariales en el sector, impidiéndose las injustas ventajas competitivas en materia de costes laborales entre empresas del mismo ramo.

2) Equilibrar la fuerza vinculante de los convenios de sector con la flexibilidad de las normas convencionales en ámbitos inferiores, “previendo los necesarios contrapesos y cautelas que no distorsionen la capacidad competitiva de las empresas ni reduzcan las condiciones laborales de las personas trabajadoras” (Preámbulo del Real Decreto-ley 32/2021). De este modo, los convenios de empresa siguen teniendo prioridad aplicativa en aspectos organizativos adecuados a ese nivel de negociación como los horarios, la adaptación de la clasificación profesional o las medidas para favorecer la corresponsabilidad (art. 84.2 ET), mientras que la negociación colectiva sectorial recupera su prioridad en aspectos que permiten evitar la devaluación salarial.

3) Adoptar medidas para evitar que las contratas y subcontratas sean utilizadas como instrumentos para la reducción de costes, mediante la devaluación de las condiciones laborales de su personal. A tal efecto, el nuevo apartado 6 del art. 42 ET establece que el “convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo dispuesto en el título III”. En este sentido, como señala el Preámbulo del Real Decreto-ley 32/2021, “la externalización debe justificarse en razones empresariales ajenas a la reducción de las condiciones laborales de las personas trabajadoras de las empresas contratistas”, lo que además de ser legítimo, garantiza “el principio de no discriminación tal y como ocurre en el caso de puestos, profesiones o sectores con alta ocupación femenina (v. gr. colectivo de camareras de piso), y donde resulta difícilmente defendible que dos personas que realizan trabajos de igual valor tengan condiciones

laborales diferentes, o incluso carezcan de marco sectorial de referencia, por razón exclusivamente del objeto social o forma jurídica de la empresa contratista o subcontratista a la que se vinculan”. Ello, no obstante, en el inciso final del art. 42.6 ET, se señala que “cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se aplicará este, en los términos que resulten del artículo 84”, norma que establece, en su apartado 1, como regla general, la prioridad aplicativa del convenio anterior en el tiempo no denunciado, regla general que cuenta con relevantes excepciones.

4) Poner fin a la limitación temporal de la ultraactividad, reducida a un año desde el agotamiento de la vigencia del convenio. El nuevo art. 86.4 ET, en su inciso final, prevé que, sin perjuicio del desarrollo y solución final de los procedimientos de mediación y arbitraje previstos en este apartado, “en defecto de pacto, cuando hubiere transcurrido el proceso de negociación sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo”. De este modo, se recupera el sosiego que requiere todo proceso negociador, y se pone fin a la falta de seguridad jurídica y a las muchas dudas interpretativas que generaba la regulación anterior.

Como señala su Preámbulo, el Real Decreto-ley 32/2021, no solo es una norma ambiciosa y equilibrada, sino que, además, cuenta con firmes perspectivas de estabilidad, al ser la primera reforma laboral de gran calado durante el presente periodo democrático que cuenta con el respaldo del diálogo social. Tras un largo proceso negociador, las organizaciones sindicales y patronales CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, el 23 de diciembre de 2021, acordaron junto con el Gobierno de la Nación las importantes medidas hoy contenidas en este real decreto-ley.

La reforma laboral de 2021, al modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, pone fin exitosamente a una perniciosa dinámica seguida durante las últimas décadas, que ha conducido a la sistemática e irreversible pérdida de derechos laborales bajo argumentos puramente económicos; todo un contrasentido, dado que, precisamente, el Derecho del Trabajo nació como resistencia frente a la lógica de las puras decisiones económicas.

Es loable que el diálogo social haya hecho posible cambiar la tendencia de regresión continua de los derechos laborales producida durante décadas, y que, entre otros logros, haya conseguido restablecer la correlación de fuerzas entre el poder sindical y empresarial existente antes de la reforma de 2012, eliminando la prioridad aplicativa absoluta del convenio de empresa en materia salarial, restableciendo el equilibrio tradicionalmente existente entre la ley y el convenio en la fijación de la estructura negocial, suprimiendo el límite temporal de la ultraactividad, y poniendo fin a la precarización extrema de las condiciones de trabajo en las empresas multiservicios.

Sin duda, el Real Decreto-ley 32/2021 supone un significativo avance en orden a garantizar el desarrollo del trabajo asalariado en condiciones laborales dignas. De este modo, el derecho del trabajo está recuperando su identidad y razón de ser, lo que es una cuestión de especial relevancia pues, como declara la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (1917), “una paz duradera solo puede ser establecida sobre la base de la justicia social”.